LICENCE 3 · SEMESTRE 5 · FICHE DE RÉVISION

Théorie des libertés fondamentales



Christophe Mondou · Université de Lille

Édition 2026-2027

Acteurs · Fondements · Exercice · Protection

Le cours ne passe pas en revue chaque liberté. Il fait un **état des lieux** de l'encadrement juridique des droits et libertés, en quatre thèmes : **qui** en est titulaire et qui en est débiteur, **sur quoi** ils reposent (philosophie et sources), **comment** ils s'exercent (en temps ordinaire et en temps de crise), et **comment** on les protège (démocratie, juges, autorités administratives). Fil rouge : les libertés ne sont **jamais définitivement acquises**.

Définition · Texte · Jurisprudence · Exemple · Piège · À retenir

Sommaire

Introduction : la diversité terminologique (libertés publiques, libertés et droits fondamentaux, droits de l'homme)

Thème 1 : la multiplicité des acteurs des libertés

- Les autorités publiques (pouvoirs publics ; personnes morales de droit public)
- Les personnes privées (titulaires : personnes physiques et morales ; obligées : effet horizontal)

Thème 2 : le dualisme des fondements des libertés

- Fondements philosophiques : droit positif, droit naturel
- Fondements juridiques : l'histoire (reconnaissance, instabilité, consécration ; catégories et générations de droits) ; les sources actuelles (traditionnelles, constitutionnalisation, internationalisation, droit de l'UE) et leurs relations

Thème 3 : l'exercice variable des libertés

- En période ordinaire : autorités compétentes ; régimes répressif et préventif ; déclaration préalable ; limites
- En période exceptionnelle : article 16, état de siège, état d'urgence, état d'urgence sanitaire, circonstances exceptionnelles

Thème 4 : la protection complexe des libertés

- La démocratie politique

- La protection juridictionnelle (procès équitable ; Conseil constitutionnel, juge administratif, juge judiciaire ; CEDH, CJUE, juridictions pénales internationales)
- La protection non juridictionnelle (organes ONU, Conseil de l'Europe, UE ; Défenseur des droits, CNIL, CNCDH ; transparence administrative)

Synthèse

INTRODUCTION

Les mots des libertés

Une actualité chargée remet les libertés au premier plan : la **liberté d'expression** (rapport du Sénat sur les « zones grises » de l'information et l'idée d'un observatoire de la désinformation ; concerts de P. Bruel, qui rappellent l'affaire *Dieudonné* ; caricatures et « liberté d'offenser », R. Ogien) et la **liberté personnelle** (CC, **23 juill. 2026, n° 2026-906 DC**, loi sur la sécurité, la rétention administrative et la prévention des attentats : conformité avec réserves ; les atteintes à la liberté personnelle, protégée par les art. 2 et 4 DDHC, doivent être **adaptées, nécessaires et proportionnées**). Plus largement : Covid, terrorisme, et le recul de la pluralité et de la nuance (T. Bauer, *Vers un monde univoque*, 2024).

1. Une terminologie flottante

On parle de « libertés publiques », « libertés fondamentales », « droits fondamentaux », « droits de l'homme », voire « libertés civiles ». **Aucune définition textuelle**, aucun consensus. Les textes eux-mêmes varient : DDHC 1789 (droits de l'homme et du citoyen) ; Constitution de 1793, art. 9 (« liberté publique ») ; Constitution de 1852, art. 25 (Sénat gardien des « libertés publiques ») ; Constitution de 1958 : art. 34 (« garanties fondamentales… pour l'exercice des libertés publiques »), art. 53-1 (« droits de l'homme et libertés fondamentales »), art. 61-1 (« droits et libertés que la Constitution garantit »), art. 71-1 (« droits et libertés »). L'enseignement lui-même est passé des « libertés publiques » (1954) au « droit des libertés fondamentales » (après 1997).

2. « Liberté », « droit de », « droit à »

Liberté et « droit de »

La **liberté** : condition de celui qui n'appartient à aucun maître et peut agir ou ne pas agir sans contrainte, dans les bornes de la vie en société (art. 4 et 5 DDHC). Le « **droit de** » (faculté de faire ou de ne pas faire) en est proche. Il appelle une simple **abstention** des autres et des pouvoirs publics.

« Droit à » (droit-créance)

Droit au travail, au logement, à l'éducation, à la protection : il faut une **prestation**, une obligation imposée à autrui. Nuance de **R. Capitant** : la liberté a toujours été une créance ; on a seulement ajouté une créance de prestation à la créance d'abstention.

L'IVG, CAS D'ÉCOLE

LC n° **2024-200 du 8 mars 2024** : nouvel alinéa de l'art. 34 : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la **liberté garantie** à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. » Une liberté qui suppose l'intervention d'un tiers : faut-il obliger les médecins (et que devient la **clause de conscience**) ou ne rien prévoir (et que devient la garantie) ?

Les libertés n'existent réellement que **consacrées par le droit**. Les « droits de l'homme » (inhérents à la nature humaine, antérieurs et supérieurs à l'État : art. 2 DDHC, liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression) ne deviennent effectifs qu'une fois **juridicisés** et invocables. Critiques : M. Villey, B. Binoche. Parfois, le droit n'est reconnu que comme **objectif à valeur constitutionnelle**, opposable à l'État mais non invocable comme tel : **logement décent** (CC, 98-403 DC, 29 juill. 1998, *Lutte contre les exclusions*), **protection de la santé** (CC, 2022-835 DC, 21 janv. 2022, sur l'al. 11 du Préambule de 1946). À l'inverse, le **droit à l'emploi**, non justiciable, a été qualifié de droit (CC, 98-401 DC, 10 juin 1998). La cohérence d'ensemble n'est pas évidente.

3. « Publiques » ou « fondamentales » ?

- **Libertés publiques** : expression fréquente (Constitutions de 1793, 1852, art. 34 C. 58 ; CC, 96-373 DC, 9 avr. 1996 ; CE, Ass., 24 janv. 1975, *Rome-Paris Films* ; TGI Lyon, 1977, *Bugey-Malville*), jamais définie : elle désigne les libertés et « droits de » **reconnus et protégés par la loi**.
- **Libertés fondamentales** : CEDH ; **référé-liberté** (art. L. 521-2 CJA).
- **Droits fondamentaux** : CC, 93-325 DC, 13 août 1993 (asile, droits de la défense) ; Cass. AP, 30 juin 1995. Parfois « fondamental » qualifie un droit (propriété : CC, 81-132 DC, 16 janv. 1982, *Nationalisations*).

CC, 84-181 DC, 10-11 OCT. 1984, ENTREPRISES DE PRESSE

La liberté de communication des pensées et des opinions est une **liberté fondamentale**, d'autant plus précieuse que son exercice garantit le respect des autres droits et de la souveraineté nationale : la loi ne peut la réglementer **qu'en vue de la rendre plus effective** ou de la concilier avec d'autres règles ou principes constitutionnels. Deux sens de « fondamental » : **non juridique** (essentiel) et **juridique** (protégé au plus haut niveau : Constitution ou traité).

Mais tous les droits constitutionnels ou conventionnels ne sont pas forcément « fondamentaux » au sens du référé-liberté : le Conseil d'État qualifie parfois une liberté fondamentale à partir de simples dispositions législatives (pluralisme : CE, ord., 24 févr. 2001, *Tiberi* ; communication : CE, 15 mai 2002, *Baudouin*).

Critère (L. Favoreu)	Libertés publiques	Libertés et droits fondamentaux
Norme de référence	La **loi**	La **Constitution** et les **traités**
Juge compétent	Juridictions ordinaires	Juge constitutionnel ou international
Nature de la protection	Verticale (contre l'État)	Verticale **et horizontale** (entre particuliers)
Bénéficiaires	Personnes physiques	Personnes physiques **et morales**

Distinction relativisée par le Conseil lui-même, qui évoque parfois les « libertés publiques constitutionnellement protégées » (CC, 94-352 DC, 18 janv. 1995, *Sécurité*).

THÈME 1

La multiplicité des acteurs des libertés

L'ancien schéma (des pouvoirs publics qui organisent, des personnes physiques qui bénéficient) est dépassé : bénéficiaires et « **obligés** » (débiteurs) sont **à la fois** des autorités publiques et des personnes privées.

1 Les autorités publiques

▸ 1.1 Les pouvoirs publics : des obligés

- La Constitution de 1958 pose peu d'obligations explicites (à la différence de l'art. 1-3 de la Loi fondamentale allemande, qui lie les trois pouvoirs aux droits fondamentaux). Mais l'**art. 1er** (égalité) et l'**art. 62** (autorité des décisions du CC) s'imposent à tous les pouvoirs publics.
- Le respect des droits est assuré par les **contrôles juridictionnels** : le législateur par le CC, l'administration par le juge administratif ; les juges ordinaires doivent respecter les décisions et **réserves** du CC.
- **Apport de la CEDH** : on passe d'une obligation d'abstention à des **obligations positives**, conséquence de l'application horizontale. CEDH, 9 déc. 1994, *López Ostra c/ Espagne* (domicile protégé contre les émanations d'une station d'épuration privée) ; CEDH, 23 sept. 1998, *A. c/ Royaume-Uni* (protéger un enfant contre les châtiments corporels d'un beau-père). Limite par la proportionnalité : CEDH, 25 mai 1998, *Kurt c/ Turquie*.

▸ 1.2 Les personnes morales de droit public : des titulaires

Elles bénéficient de droits, plus limités (R. Drago ; critique de X. Bioy) : **égalité** pour les établissements publics (CC, 79-112 DC, 9 janv. 1980) ; **propriété** et **libre administration** pour les collectivités (CC, 82-137 DC, 25 févr. 1982 ; CE, Sect., 18 janv. 2001, *Commune de Venelles*), égalité dans une certaine mesure ; question de la CEDH (CE, Sect., 29 janv. 2003, *Commune de Champagne-sur-Seine*) ; et le **droit au recours**.

2 Les personnes privées

▸ 2.1 Les titulaires de droits

A. Les personnes physiques : bénéficiaires principaux. Le droit ne définit pas l'« humain » mais le **qualifie** (art. 16 C. civ., personnalité juridique, dignité). Le développement des droits fondamentaux a conduit à une **catégorisation** de plus en plus fine, pour rétablir une égalité réelle, ce qui exige des critères :

Catégorie	Critère et difficultés
Femmes / hommes	Apparence ? déclaration de la personne ? déclaration à l'état civil (art. 57 C. civ.) avec changement possible (art. 61-5) ? Difficultés dans le sport de haut niveau (CEDH, **11 juill. 2023, *Semenya c/ Suisse*** : discrimination et atteinte à la vie privée). CEDH, **6 avr. 2017, *A.P., Garçon et Nicot c/ France*** : le changement de sexe à l'état civil ne peut exiger une opération ou un traitement (art. 8) ; déjà CEDH, 25 mars 1992, *B. c/ France*
Mineurs	L'âge : 18 ans, mais aussi la majorité sexuelle à **15 ans** (art. 227-25 C. pén.). Notion née en 1832 (11 ans), relevée à 13 ans en 1863. Définie par CC, **2011-222 QPC, 17 févr. 2012** : âge à partir duquel un mineur peut valablement consentir à une relation sexuelle avec un majeur qui n'a pas autorité sur lui
Citoyens / étrangers	Le titre d'identité. **Citoyens de l'UE** : mêmes droits que les nationaux, sauf droits politiques (vote et éligibilité aux seules municipales et européennes) ; dir. 2004/38/CE ; CJCE, 17 sept. 2002, *Baumbast* ; CJCE, 2 oct. 2003, *Garcia Avello*. **Étrangers réguliers** : mêmes droits sauf les droits politiques, dont le droit de mener une **vie familiale normale** (CE, Ass., 8 déc. 1978, *GISTI* : regroupement familial, mariage). **Étrangers irréguliers** : un minimum lié à la **dignité** (ne pas être traité en objet), parfois davantage (aide juridictionnelle si leur situation est particulièrement digne d'intérêt)

B. Les personnes morales de droit privé (sociétés, syndicats, associations ; Y. Guyon) : reconnaissance récente mais acquise, sans texte constitutionnel en France (à la différence de l'Allemagne, art. 19-3, ou du Portugal, art. 12-2), mais avec la **QPC**. Droits reconnus : propriété, **domicile** (CEDH, 16 avr. 2002, *Société Colas Est c/ France* ; CE, 7 oct. 2022), recours, accès aux documents, saisine des autorités indépendantes, pétition devant le Parlement européen. Mais la Cour de cassation leur refuse un droit à la **vie privée** (Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-14.072).

▸ 2.2 Les personnes privées obligées : l'effet horizontal

La ***Drittwirkung*** (doctrine allemande ; J. Rivero) : les droits s'appliquent dans les **rapports entre particuliers**. Prévue par certaines constitutions (Espagne, Italie, Portugal) ; en France, indirectement par l'**art. 4 DDHC**. Aujourd'hui acquise : que vaudraient des droits fondamentaux inapplicables dans les relations privées ? (J. Raynaud ; D. Spielmann).

QUESTION OUVERTE DU COURS

Les droits fondamentaux doivent-ils être réservés aux humains ? Débats sur les **animaux** (Déclaration universelle des droits de l'animal, 1978 ; C. Vial) et les **robots** (S. Slama).

THÈME 2

Le dualisme des fondements des libertés

1 Les fondements philosophiques

▸ 1.1 Le droit positif

Une chose n'existe que si un texte (surtout une loi) la reconnaît.

Positivisme normatif

Les droits sont ceux que les textes reconnaissent dans un État donné (seules des **libertés publiques** existent). La question n'est pas de savoir si la loi est juste, mais si elle est valable : *dura lex, sed lex* ; Montaigne (on obéit aux lois parce qu'elles sont les lois) ; Montesquieu (le juge, « bouche de la loi »). Avant le contrôle de constitutionnalité, la loi pouvait donc restreindre les libertés sans difficulté juridique.

Positivisme sociologique

Le droit évolue avec l'état de la société (A. Comte) : loi Veil (1974-1975), pacs (1999), mariage pour tous (2013), PMA (2004, 2011). Quel rythme d'adaptation, y compris pour la Constitution (comité Veil, 2008) ? **Risque** : un peuple qui ne voudrait plus de certaines libertés au nom de la sécurité. À l'inverse, la loi **Badinter du 9 oct. 1981** abolit la peine de mort contre l'opinion majoritaire.

Deux problèmes du droit positif : 1) le **fondement** sur lequel s'appuient les auteurs des textes (une majorité parlementaire inspirée par des considérations économiques, morales ou religieuses, ce qui heurte notamment la laïcité) ; 2) la **modification** plus ou moins facile des textes (Constitution : référendum ou 3/5 du Congrès, toujours une logique majoritaire ; traités : difficiles à modifier mais d'application incertaine, conditions des art. 54 et 55, d'où l'intérêt d'une juridiction comme la Cour EDH). Ex. : faut-il qu'une majorité simple décide du libre usage du corps ?

▸ 1.2 Le droit naturel (jusnaturalisme)

Droit naturel classique (objectif)

Aristote, **saint Thomas d'Aquin** : le droit résulte de la **nature des choses** observée (ce qui a pu justifier l'esclavage chez Aristote), puis de la nature humaine révélée par Dieu chez saint Thomas. Influence aujourd'hui disparue.

Droit naturel moderne (subjectif)

Guillaume d'Occam, **Hobbes**, **Locke**, **Rousseau** : l'homme a des droits **avant toute société**, sans référence religieuse, d'où un droit de se révolter. Traduction : **art. 2 DDHC** (droits naturels et imprescriptibles) ; **Déclaration d'indépendance du 4 juill. 1776** (vie, liberté, recherche du bonheur ; droit de changer de gouvernement). Ce sont les **droits subjectifs**.

Limites : s'ils sont naturels, ils ne devraient pas avoir besoin d'un texte (alors que, en droit positif, ils n'existent que par lui) ; **aucune liste** n'en existe (l'art. 2 DDHC n'a qu'une valeur relative) ; risque d'**individualisme**, chacun définissant « ses » droits au mépris des contraintes de la vie en société.

BILAN ET PISTES DU COURS

Nous sommes surtout influencés par le **droit positif** (sous ses deux formes) et en partie par le **droit naturel subjectif**. Pistes inspirées de B. Leoni et R. Ogien : adopter les textes touchant aux libertés à l'**unanimité** ou au moins à une **majorité renforcée**, sinon laisser les juges trancher (comme pour les mères porteuses avant la loi) ; refuser les restrictions fondées sur des considérations purement **morales** et s'en tenir au principe de **ne pas nuire à autrui** (art. 4 DDHC ; « éthique minimale » d'Ogien), en sachant que ce qu'est « nuire » (offenser ?) reste discuté (voir l'affaire *Mila* et la jurisprudence de la Cour EDH sur le blasphème). Question : faut-il renoncer à certains droits pour vivre ensemble ? (J. Arroyo, *La renonciation aux droits fondamentaux*).

2 Les fondements juridiques

▸ 2.1 L'histoire mouvementée des libertés

A. Les trois étapes

- **1. La reconnaissance (1215-1789)**. Angleterre : **Magna Carta** (1215, Jean sans Terre : circulation, présomption d'innocence) ; **Pétition des droits** (1628, contre l'absolutisme de Charles Ier) ; ***Habeas corpus*** (1679 : être présenté sans délai à un juge) ; **Bill of Rights** (1689). Amérique : déclaration de **Virginie** (12 juin 1776), **Déclaration d'indépendance** (4 juill. 1776, Jefferson), **dix premiers amendements** à la Constitution de 1787 (1er : religion, parole, presse, réunion ; 2e : port d'armes ; 4e : vie privée et domicile ; 5e : *non bis in idem*, ne pas témoigner contre soi, propriété ; 6e : impartialité ; 8e : proportionnalité des peines). France : **DDHC du 26 août 1789**, texte de compromis.
- **2. L'instabilité (1793-1944)**. 1793 : nouvelle déclaration (devoirs de la société, prémices des droits sociaux) ; 1795 : individualisme forcené, disparition de l'art. 1er et de la résistance à l'oppression ; période bonapartiste et chartes : plus de déclaration, droits réservés aux Français (sauf religion et propriété) ; **1848** : abolition de l'esclavage, suffrage universel, libertés collectives et devoirs de la société, mais peu effectifs ; Second Empire : rappel des principes de 1789, libéralisation après 1860 ; **IIIe République** : « âge d'or des libertés publiques », les **grandes lois de la République** (mais aussi l'état de siège de 1914, et des dispositions qu'on jugerait aujourd'hui contraires à la CEDH) ; **Vichy** : disparition des libertés ; la Libération n'est pas toujours respectueuse non plus.
- **3. La consécration (depuis 1946)**. **Préambule du 27 oct. 1946** : droit naturel moderne (droits inaliénables et sacrés), droits économiques et sociaux (« principes particulièrement nécessaires à notre temps »), renvoi à 1789 et aux **PFRLR**. Restrictions sous la IVe : loi du 3 avr. 1955 (état d'urgence en Algérie), loi du 16 mars 1956 (pouvoirs spéciaux).

LES TROIS PRINCIPES DE LA DDHC DE 1789

- **Universalisme** : droits de l'être humain : égalité (art. 1er et 6), liberté (art. 1, 2, 4 ; opinion et religion, art. 10 ; communication, art. 11), propriété (art. 17), sûreté (art. 2, avec les garanties des art. 7, 8 et 9), résistance à l'oppression (art. 2). S'y ajoutent des droits du **citoyen** (art. 6, 14, 15) et des devoirs (art. 7, 12).
- **Individualisme** : uniquement des « **droits de faire** », pas de droits-créances ni de droits collectifs (sauf presse et manifestation des idées).
- **Légicentrisme** : rôle central de la loi (art. 4, 5, 8).

Le mouvement international : avant 1945, des textes humanitaires (conventions de 1864 et de La Haye ; abolition de l'esclavage, acte général de 1890 et convention de 1926 ; convention de l'OIT de 1929 sur le travail forcé), mais aucune liste générale des droits.

Niveau	Textes	Observations
Mondial (ONU)	**DUDH, 10 déc. 1948** ; **deux Pactes du 16 déc. 1966** (droits civils et politiques ; droits économiques, sociaux et culturels) ; conventions spécialisées (esclavage 1926 et 1956 ; génocide 1948 ; discrimination raciale ; femmes 1979 ; réfugiés 1951 ; apatrides 1954 ; migrants 1990 ; enfants 1989)	La DUDH est un compromis libéral / marxiste, avec des silences (grève, commerce) et des ambiguïtés (procès équitable, élections honnêtes). **Simple déclaration d'intention, sans valeur juridique** ; les Pactes en sont l'équivalent ratifié
Paneuropéen (CSCE)	Acte d'**Helsinki** (1975) ; documents de **Copenhague** (28 juin 1990) et Charte de **Paris pour une nouvelle Europe** (21 nov. 1990)	Des structures de vérification (centre de prévention des conflits, bureau des élections libres) mais **aucun juge**
Conseil de l'Europe	**CEDH, 4 nov. 1950** ; **Charte sociale européenne** (18 oct. 1961 : grève, liberté syndicale, droits-créances ; les États choisissent les droits qu'ils acceptent, avec un minimum) ; conventions sur la torture (1987), la participation des étrangers à la vie locale (1992), les droits de l'enfant (1996), la biomédecine (Oviedo, 1997), les relations personnelles des enfants (2003)	La France n'a ratifié la CEDH qu'en **1974** (loi du 31 déc. 1973, décret du 3 mai 1974 ; réticences sur la Cour et l'art. 16) ; recours individuel accepté en 1981. Droits classiques (la propriété arrive par protocole), distinction entre droits **intangibles** et droits susceptibles de limites « nécessaires dans une société démocratique », interdiction de l'abus de droit (pas de protection des « liberticides ») ; la révolution vient de la **Cour**
Union européenne	Traités de Paris (1951) et Rome (1957) : libertés économiques, non-discrimination ; **CJCE, 14 mai 1974, *Nold*** : les droits fondamentaux font partie des **principes généraux du droit** dont la Cour assure le respect	Principes découverts : égalité, légalité, sécurité juridique, droits acquis, droits de la défense, non-rétroactivité pénale, vie privée, *non bis in idem*, bonne foi. Puis la Charte des droits fondamentaux (voir plus bas)

B. La progression des droits

- **Le développement catégoriel** : droits spécifiques des personnes vulnérables. **Femmes** (lutte contre les discriminations et violences ; quotas, qui ont exigé la révision de **1999** sur la parité) ; **enfants** (de

l'enfant protégé de la Déclaration de 1959 à l'enfant **sujet de droits** de la Convention de 1989) ; salariés, personnes défavorisées, malades et handicapés, détenus, personnes âgées, étrangers et réfugiés (Charte de l'UE).

- **Les « générations » de droits** (N. Tenzer) :

Génération	Contenu	Exemples
1re (XVIIe-XVIIIe s.)	**Droits-libertés**, civils et politiques, d'inspiration libérale et individualiste, contre l'État	Égalité devant la loi, sûreté, propriété, conscience, expression, opinion
2e (proclamés tôt, consacrés après 1945)	**Droits-créances**, économiques, sociaux et culturels	Travail, éducation, santé, famille, loisirs, culture, asile, grève, liberté syndicale
3e	Droits de **solidarité**, des générations futures, « droits pour » (D. Rousseau)	Environnement sain, développement durable, eau, air, paix, patrimoine commun. **Charte de l'environnement** (2005). CC, 2022-843 DC, 12 août 2022 ; CC, **2023-1066 QPC, 27 oct. 2023** (Bure : ne pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins)
4e	Droits liés au **numérique** et aux progrès de la **biomédecine**	Accès aux services en ligne ; euthanasie, disposition du corps, PMA, droits reproductifs (A. Gautier) ; clonage (A. Jacquard)

Critique de l'idée de générations : une génération ne **remplace** pas l'autre ; les droits sont **indivisibles** et interdépendants (M.-J. Redor-Fichot ; M.-C. Ponthoreau ; la Charte de l'UE classe les droits par valeurs et non par nature). Pour d'autres, les nouvelles générations menacent la première (l'environnement contre la liberté d'entreprendre, M. Gros). Nouveau défi : l'**IA** (surveillance biométrique, biais, désinformation, données personnelles), encadrée par le **RGPD**, la loi de 1978, la CNIL et le **règlement européen sur l'IA** (RIA), dont l'**art. 27** impose aux déployeurs publics (et à certains déployeurs privés, banques, assurances) une **analyse d'impact sur les droits fondamentaux** avant tout déploiement d'un système à haut risque (avis CNCDH, 7 avr. 2022 ; rapports du Défenseur des droits).

▸ 2.2 Les fondements juridiques actuels

A. La multiplication des sources

1. Les sources traditionnelles, aujourd'hui en **déclin** : la **loi** (art. 34 : garanties fondamentales des libertés publiques ; rien n'interdit au législateur d'en consacrer de nouvelles) ; les **principes du juge administratif** : **PGD** (aller et venir, égalité, liberté du commerce et de l'industrie, vie familiale normale, droits de la défense) et **PFRLR** découverts par le CE (liberté d'association ; non-extradition pour motif politique).

2. Les nouvelles sources

a) La constitutionnalisation. La Constitution de 1958 n'a pas de déclaration propre, seulement un préambule de valeur incertaine, l'art. 66 (sûreté, juge judiciaire), des régimes d'exception, et un contrôle de constitutionnalité au rôle d'abord ignoré. Rien ne bouge jusqu'en 1971.

CC, 71-44 DC, 16 juill. 1971, Liberté d'association

Le Conseil reconnaît valeur constitutionnelle au **Préambule de 1958**, et donc à la **DDHC de 1789**, au **Préambule de 1946** et aux **PFRLR** (naissance du « bloc de constitutionnalité »). Rendue décisive par la révision du **29 oct. 1974** (saisine par **60 députés ou 60 sénateurs**), qui arme l'opposition : première saisine parlementaire sur la loi Veil (CC, 74-54 DC, 15 janv. 1975). Le Conseil numérote ensuite les alinéas de 1946 et mobilise les articles de 1789 (dès 1973), surtout l'égalité.

Les PFRLR : conditions de découverte

Une **législation républicaine** antérieure à 1946, **sans exception**, portant sur une norme **suffisamment générale** et d'un **intérêt important**. C'est le **principe sous-jacent** qui acquiert valeur constitutionnelle, pas la loi : pour 1901, la libre constitution des associations sous le seul régime déclaratif. Âge d'or 1971-1981, puis découvertes plus rares (2002 : responsabilité pénale atténuée des mineurs) et refus.

Décision	Apport
CC, **2022-1004 QPC, 22 juill. 2022**, *Associations diocésaines*	Liberté d'association = PFRLR ; les atteintes doivent être **nécessaires, adaptées et proportionnées**. La déclaration de qualité cultuelle (art. 19-1, loi de 1905) n'encadre pas la constitution de l'association ; mais le retrait des avantages ne peut entraîner la **restitution** de ceux déjà perçus (réserve)
CC, **2021-823 DC, 13 août 2021**, *Principes de la République*	Rappelle la liberté d'association et la liberté d'enseignement comme PFRLR, mais refuse d'y rattacher l'**instruction en famille**
CC, **2023-1069/1070 QPC, 24 nov. 2023**, *Cours criminelles départementales*	Pas de PFRLR imposant le **jury** criminel : une tradition ne compte que si elle a donné naissance à un PFRLR, or le jury a été écarté par des lois de 1875, 1928 et 1938
CC, **2025-881 DC, 7 mai 2025**	Pas de PFRLR selon lequel toute personne née en France aurait droit à la nationalité sans restriction (**droit du sol**)

Autres catégories : les **principes particulièrement nécessaires à notre temps** (1946), désormais visés par leur alinéa ; des **principes à valeur constitutionnelle**, comme la **dignité de la personne humaine**, dont l'imprécision pose problème : Cass. AP, **17 nov. 2023**, n° 21-20.723 (exposition *Infamille*, FRAC Lorraine) : la dignité ne peut être un **fondement autonome** de restriction à la liberté d'expression (artistique). Puis la **Charte de l'environnement** (2005), première réforme des droits sans changement de régime depuis 1946.

La QPC (art. 61-1, révision de 2008, en vigueur le 1er mars 2010)

Elle ne protège que les « **droits et libertés que la Constitution garantit** » et a redonné un coup de fouet au Conseil, qui a censuré de nombreuses dispositions. Inutilisable si aucun droit fondamental n'est en jeu, et pour **contraindre le législateur à légiférer** (CE, 10 oct. 2022, *Association Dignitas*, n° 465977, à propos de l'aide à mourir).

b) L'internationalisation. Les traités ne produisent effet en France que s'ils ne sont pas contraires à la Constitution (sinon révision préalable, art. 54) et remplissent les conditions de l'**art. 55** (ratification,

publication, réciprocité), puis s'ils sont **d'application directe** (critères rédactionnel et d'autosuffisance). Ex. de la **Convention des droits de l'enfant** : juge judiciaire longtemps strict, juge administratif article par article (pas d'effet direct : art. 2-1, 3-2, 12, 26-1, 27-1 ; effet direct : art. 3-1, 7, 9). La vraie révolution vient de la **CEDH** : mécanisme juridictionnel européen et invocabilité directe devant les juges français.

c) Le droit de l'Union européenne.

- **Acte unique (1986)** : référence à la CEDH, à la Charte sociale et à la Charte des Nations unies.
- **Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux (9 déc. 1989)** : droits-créances et libertés classiques, mais simple déclaration d'intention.
- **Maastricht (1992)**, art. F § 2 : l'Union respecte les droits garantis par la CEDH et issus des **traditions constitutionnelles communes**, comme principes généraux.
- **Amsterdam (1997)** : patrimoine commun de valeurs (droits de l'homme, démocratie, État de droit), condition d'adhésion et **sanction** possible d'un État en cas de violation grave et persistante ; clause générale de non-discrimination ; contrôle politique et juridictionnel.
- **Charte des droits fondamentaux (Nice, 18 déc. 2000)** : six valeurs (dignité, libertés, égalité, solidarité, citoyenneté, justice), donc **indivisibilité** ; modernise la CEDH (intégrité et bioéthique, données personnelles, procès équitable sans restriction de matière), droits sociaux (licenciement injustifié, négociation et action collectives), droits nouveaux (**bonne administration**, accès aux documents). « Citoyenneté ouverte » : seuls le vote, l'éligibilité et la protection diplomatique sont réservés aux citoyens de l'Union ; la pétition est ouverte à toute personne.

CHAMP D'APPLICATION LIMITÉ DE LA CHARTE

Elle ne vise que les institutions de l'Union et les États **lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union**, sans étendre les compétences de l'Union. L'adhésion de l'UE à la CEDH (prévue par les traités) ajouterait le contrôle de la Cour EDH. Le droit **dérivé** (règl. 1612/68 sur la libre circulation des travailleurs ; dir. 90/364 sur le séjour) a souvent plus changé la vie quotidienne (séjour d'un enfant européen et de son parent extra-européen, études, aide sociale) que les grandes proclamations. Actualité : **RGPD** et **RIA**.

B. La complexité des relations entre les sources

1. La hiérarchie. Sources internes : PGD (valeur infralégislative) < lois < Constitution au sens large (textes et principes). Les juges ordinaires refusent d'écarter une loi contraire à la Constitution : théorie de la **loi-écran** (que la QPC contourne). Traités : supérieurs à la loi (art. 55), mais **inférieurs à la Constitution** dans l'ordre interne, ce qui joue dans les deux sens :

En faveur des libertés

CE, Ass., **3 juill. 1996, *Koné*** : le PFRLR de non-extradition pour motif politique l'emporte sur un accord franco-malien.

Contre les libertés

CE, Ass., **30 oct. 1998, *Sarran et Levacher*** : la Constitution (corps électoral restreint en Nouvelle-Calédonie) prime sur la CEDH et le Pacte de 1966 invoqués pour l'universalité du suffrage. Certains États intègrent les textes internationaux dans leur Constitution (Andorre, 1993).

Droit de l'UE : pour la Cour de justice, il prime même sur les Constitutions (CJCE, 17 déc. 1970, *Internationale Handelsgesellschaft* ; 11 janv. 2000, *Kreil*). Le **CC** l'admet **sauf disposition constitutionnelle expresse contraire** (CC, 2004-496 DC, 10 juin 2004, *Économie numérique* ; 2004-505 DC, 19 nov. 2004, *Traité constitutionnel*).

2. L'interprétation. La Charte (art. 52, art. II-112 du traité constitutionnel) prévoit que les droits correspondant à la CEDH ont le **même sens et la même portée** que dans la Convention et la jurisprudence de Strasbourg, et que les droits issus des traditions constitutionnelles communes s'interprètent en harmonie avec elles. La **laïcité** française a été préservée (CC, 2004-505 DC, § 14 s.), mais les nombreuses condamnations de la France par la Cour EDH et la CJUE obligent parfois à faire évoluer notre conception des libertés.

THÈME 3

L'exercice variable des libertés

Reconnaître une liberté ne suffit pas : il faut en **rendre l'exercice possible**, et donc l'encadrer. Ex. : en 1981, la multiplication des « radios libres » rendait la réception impossible ; un pouvoir pourtant favorable à la libéralisation a dû instaurer un régime d'**autorisation**. Une liberté trop facile peut devenir impossible à exercer.

> **LES CLAUSES DE RESTRICTION DES GRANDS TEXTES**
>
> **CEDH** et **Pacte de 1966** : restrictions **prévues par la loi**, **nécessaires dans une société démocratique**, pour la sécurité nationale, la sûreté publique, l'ordre, la santé ou la morale, les droits d'autrui. **Charte de l'UE, art. 52 § 1** : toute limitation doit être prévue par la loi, **respecter le contenu essentiel** du droit, être **proportionnée**, nécessaire et répondre à un objectif d'intérêt général ou à la protection des droits d'autrui.

Tendance défavorable : l'essentiel de la loi de 1955 sur l'état d'urgence est passé dans le **Code de la sécurité intérieure** ; l'exceptionnel devient courant. Le cycle actuel n'est pas favorable aux libertés.

1 L'exercice en période ordinaire

▸ 1.1 Les autorités compétentes

A. Le législateur, autorité de principe (art. 34), mais strictement encadré depuis 1958 :

- Il doit fixer les garanties fondamentales des libertés publiques et des droits constitutionnels ou conventionnels ; toute nouvelle consécration étend sa compétence. S'il renvoie à une autre autorité, censure pour **incompétence négative**. Délégation possible par **ordonnances** (art. 38).
- Il doit rendre la liberté **plus effective** : pas de recul du niveau de protection, garanties nouvelles au moins équivalentes. Exception : suppression justifiée (CC, 79-105 DC, 25 juill. 1979 : interdiction totale de la grève pour les agents dont la présence est **indispensable**).
- Il opère la **conciliation** : entre deux libertés ; entre une liberté et un **objectif à valeur constitutionnelle** (ordre public, pluralisme des courants d'expression, logement décent) ; entre une liberté et le fonctionnement des services publics. Sans **dénaturer** la liberté.
- Il assure une application **uniforme** sur tout le territoire (les conditions essentielles ne peuvent dépendre des collectivités), et pour les droits sociaux, l'absence de rupture caractérisée d'égalité, quelle que soit la nationalité.

B. Les autorités administratives

Pouvoir réglementaire complémentaire

Compétence de principe du **Premier ministre** et du **Président** ; compétence subsidiaire des collectivités (par la Constitution), des ministres et de certaines AAI (par la loi). **Silence de la loi** : pour le CC, l'administration n'a aucun titre ; pour le juge administratif, elle peut le combler pour que la liberté s'exerce. Ex. du **droit de grève** : CE, Ass., **7 juill. 1950, *Dehaene*** (le Gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, en fixe les limites ; plus largement, chaque chef de service).

Pouvoir de police administrative

Autorités nationales (Premier ministre, ministres) et locales (**préfet**, surtout le **maire**). Possible **même sans texte**, mais **finalisé** (ordre public seulement). L'autorité recherche la mesure **adaptée** aux faits et au but ; l'interdiction n'est permise que si c'est la seule mesure possible. Une autorité inférieure peut **aggraver** la mesure supérieure si des circonstances locales le justifient.

▸ 1.2 Les régimes d'exercice

Il n'existe que **deux régimes** : répressif et préventif. Le législateur les choisit (art. 34), sous des contraintes constitutionnelles, internationales et techniques. La **déclaration préalable** n'est pas un troisième régime : elle débouche toujours sur l'un des deux.

	Régime répressif	Régime préventif
Principe	On exerce librement, en connaissant d'avance les limites, sauf à répondre des **abus** devant le **juge pénal**. Le **seul régime vraiment libéral**	On empêche l'exercice **avant** tout dommage ou trouble, en général par une autorité administrative (parfois judiciaire), par autorisation ou par interdiction
Avantages	Exercice **immédiat**, sans formalité ; **sécurité juridique** (ex. : parole libre, sauf propos racistes ou xénophobes)	Évite les troubles ; nécessaire pour certaines libertés techniques (audiovisuel)
Conditions et dérives	Respect des art. 4, 5, 7, 8 DDHC (légalité, nécessité et proportionnalité des peines, non-rétroactivité) et du *non bis in idem* (art. 50 de la Charte de l'UE). Il faut un **espace de liberté** : pas trop d'interdits, des incriminations **précises** (loi « anticasseurs » du 8 juin 1970, abrogée ; termes imprécis de la loi du 21 janv. 1995). Dépend aussi de l'usage de l'**opportunité des poursuites** et de la marge du juge. Vigilance sur l'**art. 431-1 C. pén.** (entrave concertée, avec menaces, aux libertés d'expression, de travail, d'association, de réunion ou de manifestation : quid des contre-manifestations ?)	Voir ci-dessous

1. L'autorisation préalable

Habilitation, licence, permis, agrément : **seul le législateur** peut l'instaurer ; l'administration ne peut l'inventer, même dans le silence de la loi. Tout dépend de sa marge : **compétence liée** (elle délivre si les conditions sont remplies : peu contraignant) ou **pouvoir discrétionnaire** (ex. : autorisations de radio par l'ancien CSA, aujourd'hui l'Arcom, au regard du pluralisme, de la diversité des opérateurs, de la concurrence, du financement ; spectacles sur la voie publique). Recours en annulation contre le refus. En matière de liberté fondamentale, l'autorisation doit être **expresse**.

2. L'interdiction préventive

Empêcher tout exercice au nom de l'**ordre public** (objectif à valeur constitutionnelle), même sans texte, par les autorités de police (préfets, maires : réunions, manifestations). Contrôle du juge : **procédure contradictoire** (sauf urgence) et contrôle **maximal** de **proportionnalité** (aucune autre mesure possible ?). Jamais d'**interdiction générale et absolue**.

CE, 25 JUIN 2003, ASSOCIATION SOS TOUT-PETITS

Le préfet de police interdit une manifestation sur le parvis de **Notre-Dame** : lieu très touristique, hôpital voisin susceptible d'être visé, intervention des forces de l'ordre difficile. L'interdiction est **validée**, le juge précisant qu'elle n'est pas le résultat d'une politique d'interdiction **générale et absolue** des manifestations de l'association.

C. Le système de la déclaration préalable, plus contraignant que le répressif pur, moins que l'autorisation : informer à l'avance la puissance publique.

- **Nature** : acte déclaratoire, acte-condition ; peut faire grief.
- **Compétence exclusive du législateur**. Exemples : loi du **1er juill. 1901** (associations) ; décret-loi du **23 oct. 1935**, aujourd'hui CSI (manifestations) ; loi du **31 juill. 1963** (grève dans les services publics : préavis) ; loi du **15 nov. 2001** (rassemblements festifs à caractère musical, « rave-parties »).
- **Contenu** : identité des personnes (fondateurs, organisateurs, syndicat) et modalités (date, heure, trajet).
- **Compétence liée** : l'autorité enregistre et délivre un **récépissé** (immédiatement pour une manifestation ; 5 jours pour une association ; sinon délai raisonnable), même si l'exercice paraît contraire à l'ordre public. Ce qui compte est le **dépôt**, pas le récépissé ; le défaut de déclaration est sanctionné.
- **Délais** : 5 jours avant une grève, 3 jours francs avant une manifestation (déclaration valable 15 jours), un mois ou 15 jours pour une rave-party.
- **Issue** : le plus souvent le **régime répressif** (manifestations, presse) ; parfois le **préventif** (la déclaration informe l'autorité, qui peut interdire la manifestation pour risque de trouble : art. L. 211-3 et L. 211-4 CSI).

DÉCLARATION SUIVIE D'UNE INTERDICTION ≠ AUTORISATION

Le test est le **silence de l'administration** : dans le système déclaratif, il n'empêche pas l'exercice ; dans le régime d'autorisation, il l'empêche.

▸ 1.3 Les limites aux libertés

Sauf les droits **intangibles** (vie, interdiction de la torture et des traitements dégradants), toute liberté a des limites (structure de la CEDH : articles avec ou sans paragraphe 2). Les **motifs** doivent eux-mêmes être limités pour éviter l'arbitraire. Ex. de l'**art. 10 § 2 CEDH** : formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, nécessaires dans une société démocratique pour la sécurité nationale, l'intégrité territoriale, la sûreté publique, l'ordre, la prévention du crime, la santé, la morale, la réputation ou les droits d'autrui, la confidentialité, l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Des motifs nombreux, d'où la vigilance.

2 L'exercice en période exceptionnelle

En crise, le rapport s'inverse au profit de l'ordre. Les textes l'admettent : **art. 4 du Pacte de 1966** (danger public exceptionnel menaçant l'existence de la nation, proclamé officiellement, sans discrimination) ; **art. 15 CEDH** (guerre ou danger public menaçant la vie de la nation, dans la stricte mesure où la situation l'exige ; jamais de dérogation au droit à la vie, à l'interdiction de la torture, de l'esclavage, ni à la non-rétroactivité pénale).

▸ 2.1 Les restrictions constitutionnalisées

	Article 16 : pouvoirs exceptionnels	Article 36 : état de siège
Conditions	Menace **grave et immédiate** sur les institutions, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux, **et** interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels	**Péril imminent** résultant d'une **guerre** ou d'une **insurrection armée**
Procédure	Décision du Président après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées et du CC ; message à la nation. Parlement réuni de plein droit, AN non dissoute	Décret en Conseil des ministres, **12 jours** au plus ; prorogation par le **Parlement** (voir le code de la défense)
Effets	Mesures législatives et réglementaires pour rétablir au plus vite les pouvoirs publics	Transfert des pouvoirs de police aux **autorités militaires**, pouvoirs étendus (perquisitions de jour et de nuit, interdiction de publications et de réunions, contrôle des correspondances, éloignement des étrangers), juridictions militaires
Garanties	Faibles : décision de mise en œuvre non contrôlée (acte de gouvernement), seules les mesures réglementaires sont contrôlables ; durée non contrôlée (1961 : putsch terminé en quelques jours, art. 16 maintenu jusqu'en septembre). Propositions de la commission Vedel (1992) non retenues. La révision de 2008 permet de saisir le CC après 30 jours. Responsabilité devant la Haute Cour en cas d'usage inconstitutionnel	Mise en œuvre non contrôlée, mesures contrôlées de façon favorable aux militaires ; court-circuit possible du Parlement (organisation générale de la défense, plans de défense opérationnelle). **Jamais appliqué** sous la IVe ni la Ve

▸ 2.2 Les restrictions législatives

A. L'état d'urgence de droit commun (loi n° 55-385 du **3 avr. 1955**, maintenue grâce à l'ordonnance du 15 avr. 1960, plusieurs fois modifiée ; CC, **2017-684 QPC, 11 janv. 2018**, censure de l'art. 5, 2°, sur les zones de protection et de sécurité).

- **Algérie** 1955-1962 · **Nouvelle-Calédonie** 1985 (jusqu'en 1987 par endroits) · **métropole** fin 2005 (violences urbaines) · **attentats** : 14 nov. 2015 au 1er nov. 2017 · **Nouvelle-Calédonie** 15 au 27 mai 2024.

- **Conditions** : tout ou partie du territoire (métropole, DOM, COM de l'art. 74, Nouvelle-Calédonie), en cas de **péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public** ou d'événements ayant le caractère de **calamité publique**.
- **Procédure** : décret en **Conseil des ministres**, qui fixe les circonscriptions ; prorogation au-delà de **12 jours** par la **loi**, qui en fixe la durée ; caducité en cas de renversement du Gouvernement ou de dissolution ; Parlement informé sans délai, copie des actes, contrôle et évaluation.
- **Mesures** : préfet (interdiction de circulation à certaines heures, interdiction de séjour d'une personne menaçant l'ordre public, hors son domicile) ; dissolution d'associations participant à des atteintes graves à l'ordre public ; perquisitions, assignations à résidence, remise d'armes (ministre de l'Intérieur).
- **Contrôle** du juge administratif, longtemps limité à l'**erreur manifeste** (CE, 1985, *Dagostini*), puis via le **référé-liberté**.

CE, ord., 9 déc. 2005, *Allouache et autres*

Refus du Président de mettre fin à l'état d'urgence (violences urbaines de 2005). La faculté d'y mettre fin par décret n'échappe pas au contrôle : un régime de pouvoirs exceptionnels est, dans un État de droit, **limité dans le temps et dans l'espace**. Mais vu la soudaineté des violences et le risque lors des fêtes, pas d'**illégalité manifeste**, d'où le rejet.

CE, Ass., 24 mars 2006, *Rolin et Boisvert*

Le décret déclarant l'état d'urgence n'est **pas un acte de gouvernement** (l'intervention du Parlement n'est pas certaine) ; mais la loi de prorogation le **ratifie**, sa légalité ne peut plus être discutée. Le juge vérifie que les mesures (assignations, limitées dans le temps et l'espace et contrôlées) sont justifiées. La loi de 1955 est **compatible avec l'art. 15 CEDH**.

LA LOI SILT DU 30 OCT. 2017 : L'EXCEPTION DANS LE DROIT COMMUN

Elle fait entrer dans le droit ordinaire des mesures de l'état d'urgence : **périmètres de protection** (filtrage des accès par le préfet), **fermeture des lieux de culte**, **mesures individuelles de surveillance** par le ministre de l'Intérieur à l'égard de personnes dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité.

B. Les régimes spéciaux d'urgence : zones géographiques, défense, temps de guerre, terrorisme ; plan **Vigipirate** (années 1970, toujours actif) ; nombreuses législations réduisant les garanties en cas d'urgence. Surtout, l'**état d'urgence sanitaire** :

Élément	Régime (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, art. L. 3131-12 s. CSP)
Condition	**Catastrophe sanitaire** mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population

Déclaration	Décret **motivé** en Conseil des ministres sur rapport du ministre de la santé ; données scientifiques rendues publiques ; information du Parlement
Prorogation	Au-delà d'**un mois**, par la loi, après avis du **comité de scientifiques** ; fin anticipée possible par décret
Mesures du Premier ministre	Aux **seules fins de garantir la santé publique** : circulation et transports, **confinement** (sauf déplacements indispensables), quarantaine et isolement, fermeture d'établissements recevant du public, limitation des rassemblements et réunions, réquisitions, contrôle des prix, mise à disposition de médicaments, autres mesures limitant la liberté d'entreprendre
Applications	24 mars au 10 juill. 2020 (régime transitoire jusqu'au 31 oct. 2020), puis 17 oct. 2020 au 1er juin 2021 (prorogations successives), régime de sortie jusqu'au 15 nov. 2021 puis 31 juill. 2022. Fin des régimes d'exception : loi n° 2022-1089 du **30 juill. 2022** (CC, 2022-840 DC, qui précise la notion de « territoire national », incluant la Corse et l'outre-mer)

▸ 2.3 Les restrictions validées par le juge administratif

- **Théorie des circonstances exceptionnelles** : guerre, calamité, désunion nationale. Les règles de forme et de fond s'effacent (suppression des garanties disciplinaires d'un fonctionnaire, réquisitions, interdiction d'accoster). Le juge contrôle la **réalité** des circonstances, la **durée** de la crise et l'**adéquation** de la mesure au but.
- **L'urgence** : elle permet par exemple l'**exécution d'office** de mesures administratives, même si une liberté est en jeu.

THÈME 4

La protection complexe des libertés

Les libertés ne sont jamais acquises : les aménagements locaux du **suffrage universel** en Nouvelle-Calédonie ont été admis sans grande résistance, même par la Cour EDH (CEDH, **11 janv. 2005, *Py c/ France*** : la condition de **10 ans de résidence**, qui pourrait paraître disproportionnée, est justifiée par l'histoire et le statut du territoire et par l'apaisement d'un conflit meurtrier), et la tension a resurgi en mai 2024. Un peuple peut accepter la disparition de libertés ; la démocratie n'est pas naturelle. Il faut une protection juridictionnelle **et** non juridictionnelle, sans pour autant substituer les juges ou les autorités indépendantes au peuple et à ses élus.

1 La préservation de la démocratie politique

- **Dévolution du pouvoir par l'élection** (« gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ») : suffrage **universel**, véritable **choix** de candidats (multipartisme, financement : fin du financement par les entreprises et financement public à la fin des années 1980), **mode de scrutin** fidèle et non électoraliste (le cours suggère que les électeurs puissent le choisir eux-mêmes).
- **Séparation des pouvoirs**, fonctionnelle et organique (Montesquieu). Le **fait majoritaire** rassemble exécutif et législatif : il faut des contre-pouvoirs pour l'**opposition** (saisine du juge constitutionnel). Montée de la **démocratie illibérale** (F. Zakaria) : Hongrie, Pologne, États-Unis.
- Être majoritaire ne donne pas automatiquement raison en droit : **Tocqueville** et la tyrannie de la majorité. D'où le droit de **résistance à l'oppression** (art. 2 DDHC) et l'idée que la loi injuste perdrait sa force obligatoire.
- **L'opinion** : l'opinion de masse est difficile à prendre en compte (manipulation) ; l'opinion **militante** (ONG : Amnesty International, Ligue des droits de l'homme), avec un statut consultatif auprès de l'ONU (Comité chargé des ONG, ECOSOC) et des rapports annuels, pèse davantage.

2 La protection juridictionnelle

▸ 2.1 Le cadre processuel (art. 6 CEDH ; art. 47 de la Charte de l'UE)

- **Recours effectif** devant un juge (acquis en France, parfois par interprétation de lois floues).
- Cause entendue **équitablement** (égalité des armes, droit d'être conseillé, défendu, représenté), **publiquement** et dans un **délai raisonnable**. Ces exigences ont bouleversé les procès français après les condamnations de la Cour EDH.
- Tribunal **indépendant** (recrutement, formation, carrière, **inamovibilité** ; question du CC et de la nomination politique de ses membres), **impartial** (la Cour EDH contrôle l'impartialité **objective** : ne pas être juge et partie ; pas l'impartialité subjective) et **établi par la loi**.
- **Aide juridictionnelle** (bureau d'aide juridictionnelle) et **aide à l'accès au droit** (information, orientation, assistance, consultation).

▸ 2.2 Les différentes juridictions

L'art. 66 fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la **liberté individuelle**, mais beaucoup d'autres juges interviennent, sans garantir toujours une protection complète : CE, **27 oct. 2015, *Parti lorrain*** : aucune juridiction n'est compétente pour sanctionner la violation de l'art. 5 de la Charte européenne de l'autonomie locale. Répartition : le **CC** contrôle la loi au regard de la **Constitution**, pas des traités (CC, 74-54 DC, 15 janv. 1975, *IVG*) ; la **conventionnalité** relève des juges ordinaires (*Jacques Vabre*, 1975 ; *Nicolo*, 1989).

Juridiction	Apports	Carences
Conseil constitutionnel	Contrôle a priori et a posteriori (QPC). Bloc de constitutionnalité (1971). **Statut protecteur** des libertés importantes : effet « **cliquet** » (pas de recul, jurisprudence aujourd'hui délaissée), pas de régime d'**autorisation préalable**, application **uniforme** sur le territoire, pas de **dénaturation**. Contrôle d'une loi promulguée à l'occasion d'une loi qui la modifie (CC, 85-187 DC, 25 janv. 1985, *Nouvelle-Calédonie* ; sans cela, B. Tapie a perdu ses mandats automatiquement). **Réserves d'interprétation**, parfois contraires à l'intention du législateur (1993 : contrôles d'identité préventifs subordonnés à des éléments objectifs), parfois véritables injonctions	Refus de contrôler les **lois référendaires** (CC, 62-20 DC, 6 nov. 1962), alors qu'un référendum peut restreindre les libertés. Pas de contrôle des **révisions constitutionnelles** (CC, 2003-469 DC, 26 mars 2003) : le pouvoir de révision n'a pas de limite en droit interne
Juridiction administrative	Protège contre l'administration (et les personnes privées édictant des actes administratifs), et répare. Domaine d'excellence : la **police administrative** (générale, étrangers). Recours pour excès de pouvoir ouvert **même sans texte** ; recul des **mesures d'ordre intérieur** (règlements des écoles, prisons, armées, si atteinte aux droits fondamentaux) ; PGD et PFRLR ; contrôle au moins de l'erreur manifeste, souvent de **proportionnalité** (police, expropriation). Loi du **8 févr. 1995** : **injonctions** et astreintes. Loi du **30 juin 2000** : **référé-liberté** (voir ci-dessous) ; déféré-liberté du préfet. La QPC lève l'obstacle de la loi-écran	Le référé-liberté ne peut qu'ordonner, pas annuler ; l'injonction n'est pas toujours suivie d'effet ; le juge tient compte des **moyens** de l'administration
Juridiction judiciaire	« Autorité judiciaire » = siège **et parquet** (contrôles d'identité, garde à vue, rétention des étrangers). Le juge civil prévient ou fait cesser une atteinte (séquestre, saisie ; en référé, mesures conservatoires contre un **trouble manifestement illicite** ou un **dommage imminent**) et répare (vie privée : la seule constatation de l'atteinte ouvre droit à réparation, sans faute à prouver). Le juge pénal sanctionne (livre II du Code pénal)	Lenteur, manque de moyens, impuissance face aux sites étrangers, amendes peu dissuasives pour la presse

LE RÉFÉRÉ-LIBERTÉ (ART. L. 521-2 CJA)

Ouvert à toute personne, contre tout acte ou agissement, positif ou négatif. Conditions **cumulatives** : **urgence**, **liberté fondamentale**, atteinte **grave et manifestement illégale**. Le juge ordonne toute mesure nécessaire, dans les **48 heures** ; appel dans les **15 jours** devant le juge des référés du Conseil d'État, qui statue en 48 heures.

Reconnues comme libertés fondamentales

Aller et venir, asile, demander le statut de réfugié, présomption d'innocence, pensée et opinion, propriété, commerce et industrie, libre administration des collectivités, réunion, communication, information, droit de ne pas subir un harcèlement moral, droit de vivre dans un **environnement équilibré**.

Non reconnus

Droit au travail, accès à une formation universitaire, inscription dans un établissement, droit au congé, **droit au logement**.

CEDH, 30 JANV. 2020, J.M.B. ET AUTRES C/ FRANCE

Condamnation pour la **surpopulation carcérale** (art. 3) et pour l'**ineffectivité du référé-liberté** (art. 13) : le juge fait dépendre son office des moyens de l'administration et des actions déjà engagées, ce qui est incompatible avec le caractère **intangible** de l'art. 3. Le référé est moins efficace pour les droits liés à la dignité, même si, pendant la Covid, il a parfois conduit le juge à imposer des **obligations positives**.

B. Les juridictions externes

1. La Cour européenne des droits de l'homme

- **Protocole n° 11** (1994, en vigueur le 1er nov. 1998) : suppression de la Commission, **Cour unique et permanente**, saisine directe par les individus.
- **Protocole n° 14** : **juge unique** pour les irrecevabilités manifestes ; comité de trois juges pour les affaires répétitives ; nouveau critère d'irrecevabilité : absence de **préjudice important** (sauf si le respect des droits de l'homme exige l'examen) ; règlement amiable à tout moment ; recours en **interprétation** et en **manquement** par le Comité des ministres (majorité des 2/3, sans pénalité financière).
- **Protocole n° 15** (1er août 2021) : délai de saisine ramené de **6 à 4 mois** après la décision interne définitive.
- **Protocole n° 16** (ratifié par la France le 12 avr. 2018) : **avis consultatifs** demandés par le CE, la Cour de cassation et le CC, motivés et **non contraignants**.

- **Recevabilité** : **épuisement des voies de recours internes** utiles, efficaces et adéquates (appréciation souple : CEDH, 28 juill. 1999, *Selmouni c/ France*, sept ans de procédure en première instance) ; violation invoquée **en substance** devant les juges internes ; délai de 4 mois.
- **Procédure** : filtrage, chambre (examen contradictoire, règlement amiable, arrêt au fond, définitif après 3 mois), renvoi possible en **Grande Chambre** ; **satisfaction équitable**.

- **Apports** : droits « **par ricochet** » (art. 8 et l'environnement ; art. 3 contre l'expulsion ou l'extradition vers un risque de torture) ; **effet horizontal** et obligations positives ; condamnations même pour une décision d'une cour suprême.
- **Portée des arrêts** : **déclaratoires** mais obligatoires ; l'exécution varie (exemplaire pour les écoutes téléphoniques et l'état civil des personnes transsexuelles ; insuffisante pour le délai raisonnable). Art. 622-1 et s. CPP (ex-art. 626-1) : **réexamen** d'une condamnation pénale après un arrêt de la Cour, si la violation entraîne des conséquences que la satisfaction équitable ne peut réparer. La Cour adresse parfois des **injonctions**. Pas d'effet sur les autres États, mais une **autorité interprétative**.
- **Condamnations de la France** : extradition déguisée en expulsion, délai déraisonnable, droits de la défense, présomption d'innocence, liberté d'expression, de manifestation, vie privée, secret des correspondances…

2. La juridiction de l'Union européenne : elle vérifie le respect du droit de l'UE et de la Charte par les États et les institutions. Les particuliers peuvent saisir le **Tribunal** d'un recours en annulation contre les actes dont ils sont destinataires ou qui les concernent **directement et individuellement**, dans les **deux mois** (pourvoi devant la Cour) ; ils ne peuvent pas attaquer un acte général comme un règlement.

3. Les juridictions pénales internationales

Juridiction	Fondement	Compétence
TPIY	Résolution **827** du CS, 25 mai 1993	Personnes physiques, territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 : infractions graves aux conventions de Genève, violations des lois de la guerre, crimes contre l'humanité, génocide
TPIR	Résolution **955** du CS, 8 nov. 1994	Génocide et violations graves du droit humanitaire au Rwanda (et par des Rwandais dans les États voisins) entre le 1er janv. et le 31 déc. 1994
CPI	**Statut de Rome, 17 juill. 1998**, en vigueur le 1er juill. 2002	Génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, agression, quelle que soit la qualité officielle (chef d'État compris), faits postérieurs à 2002. Place nouvelle des **victimes** (participation, réparations)

C. La complémentarité des juridictions

- **Concurrence** : les TPI ne monopolisent pas les poursuites ; compétence **universelle** des juges nationaux (conventions de Genève de 1949 ; convention contre la torture, art. 7 § 1 : extrader ou poursuivre ; coutume pour les crimes contre l'humanité et le génocide), limitée par les **immunités** (CIJ, 14 févr. 2002, *Mandat d'arrêt*). Les TPI ont la **primauté** (dessaisissement possible des juges nationaux).
- **Complémentarité** : la CPI n'intervient qu'à titre **complémentaire** (irrecevabilité si un État compétent enquête ou poursuit). Protection convergente, ex. du mariage des personnes transsexuelles : CEDH, 11 juill. 2002, *Christine Goodwin c/ Royaume-Uni* ; CJCE, 7 janv. 2004, *K.B.*
- En principe, il existe toujours **au moins un juge** compétent, quel que soit l'auteur de l'atteinte. Le cours s'interroge sur une **juridiction unique des libertés** (fusion des ordres administratif et judiciaire ?), pour que toute victime obtienne vite la cessation de la violation ou sa réparation.

3 La protection non juridictionnelle

▸ 3.1 Les organes administratifs

A. Contrôles internationaux et européens

Cadre	Organes	Fonctionnement
ONU	**Haut-Commissaire aux droits de l'homme** (depuis 1993 ; autorité morale, déclarations, coopération, soutien aux organes). **Comités conventionnels** : discrimination raciale, discrimination à l'égard des femmes, torture, droits de l'enfant, travailleurs migrants, **Comité des droits de l'homme** (Pacte de 1966), Comité des droits économiques, sociaux et culturels (1986). **Commission des droits de l'homme** (1946, rédaction de la DUDH), remplacée par le **Conseil des droits de l'homme** en 2006	**Rapports** et recommandations à l'AG, sans sanction mais avec la réprobation que crée la publicité ; **enquêtes** (en principe avec l'accord de l'État), rapporteurs spéciaux par pays ou par thème ; **plaintes individuelles** (voir ci-dessous)
Conseil de l'Europe	Charte sociale (rapports, réclamations collectives) ; **Comité européen pour la prévention de la torture** (visites des lieux de détention) ; convention-cadre sur les minorités nationales ; **ECRI** (racisme et intolérance) ; Comité des ministres ; **Commissaire aux droits de l'homme**	Le Commissaire (résolution (99) 50 du 7 mai 1999) est élu par l'Assemblée parlementaire sur une liste de trois noms, pour **6 ans non renouvelables**. Instance **non judiciaire**, indépendante : sensibilisation, conseils, identification des insuffisances, visites, rapports publics et recommandations. Il **ne traite pas les requêtes individuelles**
Union européenne	**Médiateur européen** (Maastricht, 1992) ; **Agence des droits fondamentaux** (2007)	Le Médiateur, élu par le Parlement pour la législature, traite la **mauvaise administration** des institutions de l'UE (iniquité, discrimination, abus de pouvoir, refus d'information, retard), saisi par tout citoyen ou résident dans les **2 ans** (faits non jugés, démarches préalables), ou d'office ; solution amiable, recommandation, rapport spécial au Parlement. L'Agence assiste les institutions et les États qui mettent en œuvre le droit de l'UE

Procédures conventionnelles

Ex. du **Comité des droits de l'homme** (Protocole facultatif au Pacte) : plainte d'un particulier après **épuisement des recours internes**, si la question n'est pas examinée ailleurs ; réponse de l'État sous **6 mois** ; constatations ; mesures provisoires possibles (pas d'expulsion, soins, pas d'exécution capitale). France : **lancer de nain** (26 juill. 2002 : pas de violation) ; condamnation pour la durée double du service civil des objecteurs de conscience (1er août 2000, *Nicolas et Venier*).

Procédure extraconventionnelle « 1503 »

Résolution de l'ECOSOC : groupe de travail des communications, puis des situations. Différences : **toute personne, groupe ou ONG** peut agir (pas seulement la victime) ; on **communique une situation** (pas une plainte) ; fondement : une simple résolution, donc coopération volontaire des États ; **toutes les violations** peuvent être évoquées (pas seulement les droits d'un traité), à condition d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques.

B. Contrôles administratifs français : les AAI et API (autorités publiques indépendantes, dotées de la personnalité morale). Points communs : pouvoir de décision ou d'influence (recommandations) ; indépendance = autonomie organique et financière. Certaines n'ont qu'une incidence indirecte (AMF, Commission des sondages, CNCCFP) ; pour les libertés : **Défenseur des droits**, **CNIL**, **CADA**, **Arcom** (qui a remplacé le CSA et l'Hadopi).

LE DÉFENSEUR DES DROITS (ART. 71-1 C., RÉVISION DU 23 JUILL. 2008 ; LOIS DU 29 MARS 2011)

- Remplace le **Médiateur de la République**, le **Défenseur des enfants**, la **HALDE** et la **CNDS** (ces trois dernières devenues des collèges). Autorité constitutionnelle mais pas pouvoir public constitutionnel ; autonomie financière non protégée constitutionnellement.
- Nommé par le **Président** après avis public des commissions de chaque assemblée (Claire Hédon, après Jacques Toubon et Dominique Baudis). Saisine **gratuite**, qui n'interrompt **aucun délai**.
- **Quatre missions** : droits face aux **services publics** ; **droits de l'enfant** ; lutte contre les **discriminations** et promotion de l'égalité ; **déontologie de la sécurité**.
- **Saisine** : toute personne lésée par un service public ; l'enfant, ses représentants, sa famille, les services sociaux ou une association de plus de 5 ans ; la victime d'une discrimination (ou une association de plus de 5 ans avec son accord) ; victime ou témoin d'un manquement à la déontologie. Il peut se saisir **d'office** (la personne ne doit pas s'y opposer, sauf intérêt de l'enfant ou personne non identifiée).
- **Pouvoirs** : recommandations (y compris en **équité**), médiation, transaction, saisine de l'autorité disciplinaire, proposition de sanction, publicité de ses avis, rapports annuels. Il ne peut **pas remettre en cause une décision juridictionnelle**.

CNIL (loi du 6 janv. 1978)

Autorité collégiale contre les risques des fichiers pour la vie privée et la liberté individuelle : veille technologique, avis sur les projets de textes, propositions d'adaptation, recommandations, décisions individuelles et réglementaires, rapport annuel. Rôle transformé par le **RGPD** (2016, applicable en mai 2018).

CNCDH

Née en 1947 (commission présidée par R. Cassin), transformée en 1984, déclarée « indépendante » en 1993. Elle s'intéresse à **tous les droits de l'homme** : ratifications, mise en conformité de la loi, éducation, lutte contre le racisme, situations humanitaires d'urgence, droit international humanitaire.

▸ 3.2 Les principes de fonctionnement de l'administration

- **Transparence** (loi du 12 avr. 2000, aujourd'hui **Code des relations entre le public et l'administration**) : accès simple aux **règles de droit** (mission de service public) ; accès aux **fichiers** et rectification (loi du 6 janv. 1978) ; accès aux **documents administratifs** (loi du 17 juill. 1978) et aux **archives** (loi du 3 janv. 1979, code du patrimoine) : **garantie fondamentale** des libertés publiques, donc compétence du législateur (CE, 29 avr. 2002, *Ullmann*, solution paradoxalement moins protectrice pour le requérant) ; **motivation** des décisions individuelles défavorables, notamment celles qui restreignent les libertés ou sont des mesures de police (loi du 11 juill. 1979) ; **identification** de l'agent (nom, prénom, qualité, adresse, sauf motif de sécurité) et de l'auteur de la décision.
- **Droits de la défense** : PGD applicable aux sanctions et aux mesures prises en considération de la personne : information sur les griefs dans un délai bref et une langue comprise, temps pour préparer sa défense, contestation, interprète.

SYNTHÈSE

L'essentiel à retenir

Les grandes distinctions

- Libertés publiques (loi) / libertés fondamentales (Constitution, traités) : critères de Favoreu
- « Droit de » (abstention) / « droit à » (prestation)
- Droit / objectif à valeur constitutionnelle
- Effet vertical / horizontal (*Drittwirkung*, obligations positives)
- Droit positif (normatif, sociologique) / droit naturel (classique, moderne)
- Régime répressif / préventif (autorisation, interdiction) ; déclaration préalable

Les dates clés

- **1215** Magna Carta · **1679** *Habeas corpus* · **1689** Bill of Rights
- **1776** Virginie, Déclaration d'indépendance · **1789** DDHC
- **1946** Préambule · **1948** DUDH · **1950** CEDH · **1955** état d'urgence · **1961** Charte sociale · **1966** Pactes
- **1971** *Liberté d'association* · **1974** saisine parlementaire, ratification de la CEDH
- **2000** référé-liberté, Charte de l'UE · **2005** Charte de l'environnement · **2008** QPC, Défenseur des droits · **2017** loi SILT · **2020** état d'urgence sanitaire · **2024** IVG dans la Constitution

Décisions à citer

- CC 1971 *Liberté d'association* ; 1984 *Entreprises de presse* ; 1979 *Grève* ; 2022 *Associations diocésaines* ; 2023 *Cours criminelles* ; 2023 *Bure*
- CE 1950 *Dehaene* ; 1978 *GISTI* ; 1996 *Koné* ; 1998 *Sarran* ; 2003 *SOS Tout-Petits* ; 2005 et 2006 état d'urgence ; 2015 *Parti lorrain*
- Cass. AP 2023 *Infamille* (dignité)
- CEDH *López Ostra* ; *Py* ; *A.P., Garçon et Nicot* ; *J.M.B.* ; *Semenya*
- CJCE *Nold* ; *Internationale Handelsgesellschaft*

Questions de réflexion du cours

- Est-il important de distinguer libertés publiques et fondamentales ?
- Quelles conséquences pratiques ont les droits-créances ?
- Des droits fondamentaux pour les animaux ou les robots ?
- Faut-il renoncer à des droits pour vivre ensemble ?
- Que penser de la multiplication des états d'urgence et du rôle du maire ?
- État de droit et état d'exception (ENA, 2021)

Fiche réalisée d'après le cours de Théorie des libertés fondamentales de Christophe Mondou (L3, Université de Lille, 2026-2027).